

1526207-25.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... a quantidade, dentro da ideia de tráfico no varejo, sem me olvidar das manifestações finais, a condenação é de rigor. Necessário consignar que existe uma diferença entre o tráfico de drogas no varejo e no atacado, uma vez que os criminosos que atuam no atacado carregam, normalmente, drogas em peças maiores e ainda não divididas ou misturadas conforme o caso e ainda que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1526207-25.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526207-25.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOHNATHAN SANTOS FERREIRA

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 29 de março de 2022 nesta cidade e comarca de São Paulo, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de garantir celeridade processual e ante a concordância das partes, instaurou-se audiência remota via aplicativo MICROSOFT TEAMS, sob a presidência do MM Juiz de Direito, Dr. CARLOS ALBERTO CORRÊA DE ALMEIDA OLIVEIRA, comigo Escrevente abaixo assinado, foi aberta a audiência de INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO, nos autos da ação supra referida. Presentes também à sala a Digníssima Promotora de Justiça, Dra. Eloisa Balizardo Gagliardi, o Defensor Público, Dr. Sérgio Andre Weise Chinez e o acusado; JOHNATHAN SANTOS FERREIRA, apresentado preso, escoltado e algemado, justificando-se o seu uso, nos termos da Súmula vinculante nº 11, do STF, para segurança dos presentes, uma vez que se trata de Sala de Audiências sem qualquer proteção, limitada apenas por janelas de vidro. Há enorme fluxo de pessoas, havendo fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia (funcionários, partes e público em geral), inclusive com arremesso de objetos, como já se teve notícia em dependência deste Complexo. Ademais, "O ministro Cezar Peluso reconheceu que o ato de prender um criminoso e de conduzir um preso é sempre perigoso. Por isso, segundo ele, 'a interpretação deve ser sempre em favor do agente do Estado ou da autoridade', como se colhe em <http://www.stf.gov.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=94467>. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas

as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo. Assim, foram ouvidas as testemunhas; Daniel Costa da Rocha e Flavio Heliodoro Santana. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu, nos termos do novo art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas, pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra a Dra. Promotora de Justiça, assim se manifestou; MM Juiz, o réu JOHNATHAN SANTOS FERREIRA foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei n.º 11.343/2006 c.c. art. 61, II, j do Código Penal, porque, no contexto descrito na denúncia, em plena pandemia de coronavírus (COVID 19), trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 02 garrafas contendo 3 litros de lança-perfume, substância capaz de causar dependência física e psíquica, consoante laudo de constatação de fls.12/14, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Devidamente notificado, o réu ofereceu defesa preliminar, sendo que a denúncia foi regulamente recebida (fls.77/78). O réu foi devidamente citado. Foi designada audiência de instrução em julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, sendo o réu interrogado no final do ato. É a síntese necessária. Finda a instrução criminal, observo que os fatos narrados na inicial acusatória foram satisfatoriamente comprovados em juízo, pelo que a ação penal deve ser julgada totalmente PROCEDENTE. Inicialmente, insta esclarecer que a materialidade delitiva restou amplamente elucidada por meio do auto de prisão em flagrante de fls. 01, B.O de fls. 05/09, auto de exibição e apreensão de fls. 10, bem como pelo laudo de constatação de fls. 12/14 e laudo de exame químico toxicológico de natureza definitiva de fls.127/129, que atestaram a natureza dos entorpecentes apreendidos em poder do réu, pelo relatório policial e prova oral colhida. A autoria delitiva é certa e indubitável, recaindo sobre a pessoa do denunciado. Todas as evidências acima mencionadas retratam a prática do crime descrito na denúncia. Na delegacia, interrogado, o réu negou a acusação. Disse que comprou o entorpecente de pessoa desconhecida por R\$ 200,00 para uso (fls.04). Em juízo, o réu estava com a garrafa de lança-perfume porém era para consumo. Indagado sobre o outro processo a que foi condenado também por tráfico de drogas, disse que naquele também alegou ser usuário porém de maconha e que as outras drogas que o policial disse que seriam deles não lhe pertenceriam. A negativa dos fatos pelo réu não se amolda as demais provas. Vejamos. Ouvido na fase inquisitiva o agente de segurança FLÁVIO narrou que na data dos fatos, estavam vestidos como civis e monitoravam a estação José Bonifácio. Suspeitaram do comportamento do indiciado, o qual demonstrava nervosismo e olhava a todo o tempo para os lados e para trás. Abordaram o indiciado já na estação de embarque dos trens, encontrando com ele, no interior de uma mochila vermelha que carregava, duas garrafas pet de 2 litros somando 3 litros contendo substância entorpecente parecendo ser Loló. Posteriormente foi constatado pelo laudo pericial que seria tricloroetileno (fls. 02). No mesmo sentido, o depoimento de DANIEL a fls. 03. Em juízo, o agente FLÁVIO narrou que na busca encontraram 2 garrafas de lança perfume, um pouco mais de 3 litros. Segundo ele, as drogas eram para vender. Reconhece o réu aqui presente. No mesmo sentido o depoimento do agente DANIEL em juízo. Disse que estava trabalhando na estação quando avistou o réu em atitude suspeita, estava meio nervoso e o acompanhou até a plataforma. Indagado, ele respondeu que não estava levando nada ilícito. Pediu para abrir a bolsa e constatou que ele trazia consigo 2 garrafas de lança-perfume. O depoimento dos agentes da lei, confirmado em juízo, aliadas as circunstâncias da prisão e quantidade de estupefacientes evidencia que o réu aqui presente estava praticando o comércio espúrio de estupefacientes. Não é crível que o réu transportasse tamanha quantidade de lança perfumes para uso próprio, máxime em se considerando que foi recentemente condenado a outro processo por tráfico e drogas no qual foram apreendidas substâncias diversas sendo que hoje ao ser interrogado o réu alegou que seria também usuário de maconha. Bem contextualizado, pois, o acervo probatório, com depoimento absolutamente coerente, verdadeiro e esclarecedor dos policiais, que bem retrata a veracidade da diligência e a ausência de dúvidas quanto à prática delitiva perpetrada pelo réu. Já de início ressalte-se

que o fato de as testemunhas serem guardas municipais não tem o condão de inquinar os depoimentos por eles prestados. Inicialmente, cumpre observar que as testemunhas prestaram declarações coesas, seguras e convincentes, bem expondo os fatos e a responsabilidade do réu pelo crime praticado. Ademais, suprimir o valor devido aos depoimentos única e exclusivamente pelo fato de serem funcionários públicos é, a bem da verdade, atribuir-lhes indiretamente a pecha de levianos, ao desconfiar de que mudam a versão do ocorrido no afã de legitimarem suas condutas. Ressalte-se, outrossim, que os agentes públicos, tal como as demais testemunhas, também prestam o compromisso de dizerem a verdade, estando sujeitos às penas do crime de falso testemunho (artigo 342 do Código Penal), sendo que, muitas vezes, se desmerece o depoimento dado, mas não requerem a apuração de eventual crime de falso...A bem da verdade os que sustentam o teratológico “recebimento com ressalvas” do depoimento prestado por policiais acabam por, indiretamente, colocá-los em um limbo jurídico sem qualquer razão. Isto porque, para aquela corrente, o depoimento dos policiais não é verdadeiro o suficiente para condenar e nem mentiroso o bastante para se apurar o crime de falso testemunho...Não se pode compactuar com tal forma de pensar, mormente se considerarmos que, ou bem o depoimento é verdadeiro, ou é falso! Se falso, apuraremos sua responsabilidade penal e eventualmente em seara administrativa, desconsiderando-o como elemento de prova. Ao revés, se verdadeiro o é, deverá ser meio de prova bastante para caracterizar a responsabilidade penal. Aliás, nesta esteira, não é outro o entendimento da jurisprudência francamente majoritária: “O agente da segurança é recrutado mediante concurso público para atuar em prevenção e repressão à criminalidade e não é sensato negar-lhe crédito quando, perante o mesmo Estado que o contratou, relata atos de ofício. É compromissado como qualquer outra testemunha e a circunstância de inexistir pessoa não pertencente aos quadros policiais para depor é justificável. Seria até perigoso envolver cidadãos que não são remunerados para reprimir a criminalidade em diligências potencialmente vulneradoras de irrecuperáveis bens da vida, como a narrada nesses autos” (TJSP – AC 205162-3/4 – Rel. Jarbas Mazzoni – RT733/566).

Desta forma, restou evidente que a acusação incumbiu-se de comprovar a prática delitiva pela prova oral coligida e pela materialidade consubstanciada na apreensão dos entorpecentes. Da fixação da pena e do regime inicial de cumprimento. No tocante à pena a ser imposta, algumas considerações merecem ser feitas. Na primeira fase de fixação da pena, a reprimenda deve ser estabelecida acima do mínimo legal, em razão da expressiva quantidade de estupefacientes, nos termos do art. 59 do CP, além dos péssimos antecedentes, possuindo sentença condenatória recente por tráfico de drogas (processo 1500522-16.2021.8.25.0616), ainda não definitiva. Já na segunda fase, observo a agravante da calamidade pública do art. 61, II, “j” do CP. Existe a atenuante da confissão. Finalmente, na terceira e derradeira fase, não verifico causa de aumento ou diminuição. Da imprescindibilidade do regime inicial fechado. Inicialmente, vale salientar que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu, em seu artigo 5º, inciso XLIII, que “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”. Assim, o constituinte preferiu elencar um rol de crimes que deveriam ser tratados com maior vigor, sendo insuscetíveis de “graça, anistia e fiança”, relegando ao legislador comum a previsão de outras restrições que sejam condizentes com a peculiaridade de cada infração penal. Tais restrições foram trazidas pela Lei n.º 8.072/1990, que foi substancialmente alterada pela Lei n.º 11.464/2007. Nela se encontram taxativamente elencados os delitos que são tidos por “hediondos” – seja na sua forma tentada ou consumada –, bem como as disposições relacionadas a outros pormenores, como fixação de regime inicial de cumprimento de pena e sua progressão. Analisando-se o rol do art. 1º da Lei n.º 8.072/1990, constatamos um rol de crimes que, invariavelmente, são cometidos mediante violência e grave ameaça à pessoa. Como exemplo, temos como hediondos o homicídio, o latrocínio, a extorsão mediante sequestro, entre outros. Prestigiou-se a integridade física das pessoas e a vida humana, tida esta pela Constituição como bem jurídico primário e mais relevante, do qual decorrem os demais. Como se não

bastasse, o referido delito serve como meio de subsistência de organizações criminosas evidentemente perigosas, que reiteradamente conspurcam a ordem pública e a segurança social com ataques violentos e práticas delituosas. Por meio do tráfico de entorpecentes, tais organizações conseguem somar quantias suficientemente relevantes para a compra de armas, a corrupção dos agentes estatais e para a própria manutenção do sistema criminoso, em um temerário ciclo delituoso. Mas isso não basta. Para despistar a origem espúria da pecúnia obtida através da mercancia de entorpecentes, conseguem ainda “lavar” o dinheiro obtido, depositando-o na conta de “laranjas” fielmente associados às referidas organizações criminosas. Ademais, o tráfico de entorpecentes ganha especial relevância se considerarmos os prejuízos trazidos à família do usuário, que se vê ruir aos poucos em torno da pessoa viciada, que muitas vezes disseca todo o patrimônio visando sustentar o vício, bem como abandona a residência e passa a viver nas ruas, praticando outros delitos. Assim, diferentemente de um crime comum, no qual as consequências do delito são experimentadas apenas pelo ofendido, no tráfico de entorpecentes o crime extravasa a pessoa da vítima, expandindo seus danos também aos familiares e pessoas próximas do viciado, que sofrem e sucumbem junto ao vício do ente querido. E, mais uma vez, demonstrou-se sábio o legislador, ao estabelecer no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei n.º 8.072/1990 (modificada pela Lei n.º 11.464/2007), “a pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado”. Não há dubiedades, não há obscuridades, não há ambigüidades. O dispositivo penal é de clareza solar: o regime inicial de cumprimento de pena, para o crime de tráfico de entorpecentes, deve ser o fechado. Portanto, em sendo considerado hediondo, não resta alternativa ao juiz que não impor o regime inicial fechado, por expressa e clarividente determinação legal. Pelo exposto, o órgão ministerial aguarda o decreto de INTEGRAL PROCEDÊNCIA desta ação, a fim de que o acusado seja CONDENADO nos exatos termos propostos na denúncia, com fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena. Dada a palavra à defesa do acusado, assim se manifestou: MM. JUIZ, JOHNATHAN SANTOS FERREIRA está denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Em instrução probatória oral foi ouvido apenas e tão somente os dois agentes da CPTM responsáveis pela prisão, com derradeiro interrogatório do acusado. Ao término disso, em que pesem as ponderações da nobre representante ministerial, a Defesa aponta se tratar de caso de ABSOLVIÇÃO. Os agentes declararam que o réu entrou na estação e estava nervoso, razão pela qual realizaram a abordagem. Perguntaram se havia algo ilícito na mochila e pediram para o réu abrir a mochila, tendo constatado que havia duas garrafas de dois litros de lança-perfume. O réu, em interrogatório, confessou parcialmente a prática dos fatos. Confirmou a posse da substância, mas aduziu que se trata de porte para uso. Pois bem, Excelência, nada há nos autos exceto o depoimento de um dos próprios agentes que efetuaram a abordagem do réu. Fora o parco relato dos policiais, outros indicativos não foram apresentados e muito menos averiguados por meio de uma investigação esmerada e completa. Sequer o suposto transeunte que o réu teria tentado ajudar foi arrolado como testemunha. Compulsando os autos, verifica-se que não existe prova segura para fundamentar a condenação. POSTO ISSO, REQUER A DEFESA SEJA O RÉU ABSOLVIDO PELA FLAGRANTE FRAGILIDADE DA PROVA, CONSOANTE O ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS: inicialmente, tendo em vista que o réu não foi surpreendido vendendo a droga para terceiros, não há elementos nos autos que possam infirmar a alegação de que a destinação da substância era o uso próprio (artigo 28 da lei de drogas), razão pela qual requer-se a desclassificação da conduta de tráfico para porte de drogas para uso próprio. requer-se a) a aplicação da causa de diminuição relativa ao artigo 33, parágrafo 4, da Lei 11343-06, em patamar máximo, tendo em vista que o réu preenche os requisitos legais, destacando a primariedade, ausente prova de ligação direta do réu com organização criminosa. b) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando que o réu também preenche os requisitos exigidos pelo artigo 44 do CP, lembrando aqui que a resolução nº 5 do Senado suspendeu a execução da parte do artigo 33, parágrafo 4 que vedava a conversão da pena de prisão em reprimenda alternativa; c) fixação de regime aberto, tendo em vista que o artigo 2, parágrafo 1, da Lei dos Crimes Hediondos é inconstitucional, na medida em que viola o princípio da individualização da pena.

Nesse ponto, é importante destacar o recente julgado do Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou sua jurisprudência dominante no sentido da inconstitucionalidade da fixação de regime inicial fechado para cumprimento de pena com base exclusivamente no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos). A decisão ocorreu no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1052700, de relatoria do ministro Edson Fachin, que teve repercussão geral reconhecida e mérito julgado pelo Plenário Virtual. Na ocasião foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: "É INCONSTITUCIONAL A FIXAÇÃO EX LEGE, COM BASE NO ARTIGO 2º, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.072/1990, DO REGIME INICIAL FECHADO, DEVENDO O JULGADOR, QUANDO DA CONDENAÇÃO, ATER-SE AOS PARÂMETROS PREVISTOS NO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL"; d) direito de recorrer em liberdade, em homenagem à presunção de inocência e ao direito ao duplo grau de jurisdição, assegurado pelo artigo 8º, item 2, "h" da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. JOHNATHAN SANTOS FERREIRA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei Federal nº 11.343/06. Segundo a denúncia e o que consta nos autos do inquérito policial, em síntese, no dia 28 de outubro de 2021, por volta das 22h30min, no interior da Estação de Trem José Bonifácio, nesta cidade e comarca de São Paulo, durante reconhecido estado de calamidade pública por conta da pandemia da COVID-19, o acusado possuía e trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 02 garrafas contendo 3 litros de TRICLOROETILENO ("lança-perfume"), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls.10, laudo de constatação de fls.12/14 e laudo toxicológico definitivo de fls. 127/129, oportunidade em que foi abordado e preso em flagrante delito por seguranças da CPTM. A liberdade provisória foi deferida. O réu foi intimado para a apresentação da sua defesa preliminar, a qual foi ofertada. A denúncia foi recebida no dia 15 de fevereiro de 2022. Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, bem como foi interrogado o réu. O laudo químico toxicológico definitivo foi apresentado nos autos (fls. 127/129). Em sede de debates, a acusação pediu a condenação e a defesa pediu a absolvição pela insuficiência do conjunto probatório, além de todos os benefícios legais. Apresentado o relatório, Decido. I. Não há nulidades e houve amplo contraditório. A cadeia de custódia da prova foi mantida dadas as peculiaridades do caso, a natureza do crime e a necessidade de sair rápido do local para evitar confrontos, mormente em uma estação de trem. Importante mencionar que qualquer um do povo pode prender uma pessoa que esteja em situação de flagrante delito como no presente caso, conforme determina o artigo 301 do Código de Processo Penal, sendo que o comportamento suspeito do acusado legitimou a intervenção dos seguranças. Não se pode olvidar que o volume de ilícitos que ocorrem nas estações de transportes coletivos e no seu interior são relevantes para justificar uma ação preventiva de abordagem de pessoas que possam estar demonstrando comportamento de risco. II. Não é possível a suspensão condicional do feito, uma vez que a pena mínima prevista no presente caso, em sendo procedente a ação penal, enseja uma reprimenda superior ao limite previsto no artigo 89 da Lei Federal nº. 9.099/95. O Ministério Público não quis ofertar o acordo de não persecução penal para o acusado e não houve a confissão por parte dele. Além disso, o acusado possui outro processo criminal em curso, o que inviabiliza qualquer

um dos dois benefícios. III. O réu não demonstra indícios de comprometimento da sua imputabilidade penal, motivo pelo qual não é necessária a instauração de incidente de dependência toxicológica. IV. Inicialmente, independentemente do alegado pelas partes, mas em razão da corriqueira discussão a respeito da validade e do valor das provas baseadas nas declarações de vítimas, de pessoas diretamente ligadas a elas e em depoimentos prestados por policiais, gerando discussões acaloradas e oportunas, como no caso em estudo, torna-se necessário ponderar que não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial e ideológica, bem como distanciada da realidade social. Refutar a validade de um

depoimento ou de uma declaração, baseando-se apenas na qualidade processual ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito. Se alguém é indigno de fé, que o seja por questões mensuráveis, ponderáveis e, acima de tudo, conhecidas, sendo tão grave o preconceito contra a vítima, seus prepostos e os policiais, como o é se praticado contra a pessoa do acusado. V. As substâncias apreendidas foram submetidas a exames químicos e toxicológicos (fls. 127/129), oportunidade em que os Srs. Peritos constataram que era TRICLOROETILENO, constante na lista B1 (Lista das Substâncias Psicotrópicas) e na Lista D2 (Lista de insumos químicos utilizados para fabricação e síntese de entorpecentes e/ou psicotrópicos - Sujeitos a Controle do Ministério da Justiça e Segurança Pública) da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020). A materialidade do crime está provada. VI. Ao final da instrução probatória, com base nos elementos de convicção disponíveis nos autos, em especial, os depoimentos uníssonos e seguros dos policiais, em Juízo, somado às declarações do próprio acusado, às circunstâncias em que o réu mantinha a posse sobre as drogas, a quantidade, dentro da ideia de tráfico no varejo, sem me olvidar das manifestações finais, a condenação é de rigor. Necessário consignar que existe uma diferença entre o tráfico de drogas no varejo e no atacado, uma vez que os criminosos que atuam no atacado carregam, normalmente, drogas em peças maiores e ainda não divididas ou misturadas conforme o caso e ainda que representadas por líquido. Conforme restou apurado, em síntese, no dia 28 de outubro de 2021, por volta das 22h30min, no interior da Estação de Trem José Bonifácio, nesta cidade e comarca de São Paulo, durante reconhecido estado de calamidade pública por conta da pandemia da COVID-19, o acusado possuía e trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 02 garrafas contendo 3 litros de TRICLOROETILENO ("lança-perfume"), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls.10, laudo de constatação de fls.12/14 e laudo toxicológico definitivo de fls. 127/129, oportunidade em que foi abordado e preso em flagrante delito por seguranças da CPTM. Ao ser interrogado, o acusado confirmou que estava com as drogas, mas disse que era para o seu consumo pessoal. Respeitosamente, considerando a forma de consumo das drogas apreendidas (inalação do vapor), dificilmente uma pessoa usaria tanta droga e em um espaço de apenas 03 dias. Inclusive, a droga em questão é associada a eventos de parada cardíaca e outros problemas de saúde, mormente quando usada em excesso ou por pessoas com pré-disposição cardíaca. Os seguranças responsáveis pela prisão confirmaram que o réu estava na posse das drogas. Além da quantidade de entorpecentes, o réu possui outro processo por tráfico de drogas em curso. Portanto, demonstrada a materialidade e a autoria do crime, bem como a finalidade do tráfico ilícito, a procedência da ação penal é de rigor, restando vencidos os argumentos da ilustre defesa. VII. Demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo a dosimetria das penas a serem aplicadas. Com base no artigo 68 do Código Penal, observando os elementos norteadores previstos nos artigos 42 e 43 da Lei de Tóxicos, os quais não são diversos de casos análogos, as penas básicas são fixadas no patamar mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e 500 dias multa. Na segunda fase, não há modificação pela ausência de circunstâncias modificadoras, até porque fixadas as penas básicas no patamar mínimo legal. A questão da agravante da calamidade pública impõe algumas considerações. Inicialmente, necessário um decreto que reconheça a situação de calamidade pública, sendo que no Estado de São Paulo isso ocorreu com o Decreto Estadual nº 64.879 de 20 de março de 2020, criado em face do advento da pandemia do COVID-19. Também, conforme entendimento majoritário da jurisprudência dos Egrégios Tribunais Pátrios se faz necessária a demonstração de que o estado de calamidade pública tenha de qualquer forma concorrido para o crime em questão. Portanto, o que se observa é que o critério não é apenas objetivo, devendo ser demonstrado que a situação de calamidade pública, de alguma forma, tenha permitido o crime praticado. Logo, verificamos que a nossa posição anterior de ser um critério objetivo não se sustenta no atual quadro jurisprudencial dos Egrégios Tribunais Pátrios, sendo as

reformas das decisões em sentido contrário uma constante. Nestes termos, atento ao posicionamento jurisprudencial, o qual é um modelador dos julgamentos dos magistrados de primeiro grau de jurisdição, revejo o meu posicionamento anterior para afastar a agravante da calamidade pública porque não restou demonstrado que tal situação tenha concorrido ou mesmo facilitado a prática do crime sob análise. No sentido do que foi acima exposto, destacam-se os julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça junto ao HC 625.645/SP, Relator Ministro Felix Fischer, publicado no DJe 04/12/2020; bem como o julgado no HC 632.019/SP, Relator Ministro Felix Fischer, publicado no DJe 10/2/2021; o julgado no HC 629/981/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, publicado no DJe 9/2/2021 e, finalmente, o que foi julgado junto ao HC 620.531/SP, Ministro Sebastião Reis Júnior, publicado no DJe 3/2/2021. Já na terceira fase, é de rigor o reconhecimento do redutor legal em face da primariedade do réu e a circunstância dele demonstrar arrependimento e acima de tudo não existir indícios de envolvimento com o crime organizado. Neste ponto, importante mencionar que até data próxima eu mantinha o meu convencimento quanto a não aplicação do redutor do §4º, do artigo 33, da Lei de Tóxicos, em casos envolvendo pessoas que trabalham para outros, ou seja, em situação típica de organização criminosa. Porém, as modificações reiteradas das minhas sentenças em segundo grau de jurisdição, bem como no próprio Superior Tribunal de Justiça, neste particular, demonstram que há uma tendência jurisprudencial de considera como sendo um direito subjetivo do acusado primário, talvez como uma segunda chance antes de uma pena mais severa. Em razão disso, bem como visando não prejudicar o acusado e gerar recursos desnecessários, reconheço a causa de diminuição de pena do §4º, do artigo 33, da Lei de Tóxicos, para reduzir a sanção em 2/3, o que entendo razoável dentro da quantidade e variedade de drogas apreendidas, passando para 01 ano e 08 meses de reclusão, e 166 dias multa. Fixam-se, cada dia multa, no valor mínimo unitário legal, diante da ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do acusado. O acusado poderá recorrer em liberdade e iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto. O réu está em liberdade e poderá recorrer em liberdade. Não se aplica o disposto no artigo 387, parágrafo segundo do CPP, em face da quantidade de pena imposta, o que impede a detração antecipada e a progressão de regime, até porque o regime inicial é o aberto. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, a ação penal para condenar JOHNATHAN SANTOS FERREIRA, RG/SP nº 59.848.300, nascido em 22/07/1998, natural de São Paulo - SP, filho de Jaíra Santos Ferreira, às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, com início no regime aberto, sem direito a benefícios de anistia, graça e indulto, nos termos da Lei Federal nº 8.072/90, e 166 dias multa, no seu valor mínimo unitário legal, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", §4º, da Lei Federal nº 11.343/06. Condeno o acusado ao pagamento do valor equivalente a 100 UFESP a título de custas processuais, ficando suspensa a exigência por ser beneficiário da Justiça Gratuita. Presentes os requisitos do artigo 44 e s.s. do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela prestação de serviços para a comunidade pelo tempo da pena privativa de liberdade em local a ser designado pelo Juízo das Execuções Penais, além de 10 dias, no valor mínimo unitário legal. Já existe laudo pericial definitivo não impugnado, motivo pelo qual se oficie para a destruição dos entorpecentes que ainda estejam guardados para contraprova. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do acusado rol dos culpados e expeça-se alvará de soltura clausulado. Autorizo a destruição dos demais objetos apreendidos e guardados, uma vez que relacionados com o tráfico ilícito de drogas. Publicada a sentença após o término da audiência pelo MM Juiz, foi dito que: Vistos. Intimem-se as partes e o réu para tomarem conhecimento da sentença e se manifestarem com relação a eventual recurso no prazo legal. Nos termos do artigo 1.269 e seus parágrafos e 1.270 e seus parágrafos das Normas de Serviço dos Ofícios de Justiça expedidas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, este termo é assinado eletronicamente pelo magistrado. Certifico e dou fé que as partes estão cientes sobre o respectivo teor; recebendo, Ministério Público e Defesa, caso assim solicitem, cada qual uma via assinada fisicamente pelos presentes. Registre-se e comunique-se. Autorizo Xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Wagner), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz: Assinatura Digital